

Aspectos Legales de la Internet¹

Parte 1: La Internet

Concepto:

“La Internet es una libre asociación de miles de redes y millones de computadoras alrededor del mundo, que trabajan juntas compartiendo información”

A los efectos de entender cabalmente el concepto de Internet es necesario compararla con los tipos de redes existentes al momento de la formulación de concepto. En las décadas de 1960 y 1970 las redes utilizadas en las universidades y el gobierno, eran del tipo “*Cliente- Servidor*”, en la que una computadora central o “*Mainframe*” alimentaba las distintas terminales las cuales carecían por completo de autonomía, sin que pudieran funcionar por separado.

La razón de esta estructura es el alto costo de los sistemas informáticos, los cuales ascendían normalmente a varios millones de dólares. Frente a esta realidad, la arquitectura del sistema tendía a maximizar el uso de los recursos instalados, permitiendo la utilización simultánea de la mayor cantidad de usuarios posibles.

El problema de esta estructura es la total dependencia de la misma a un centro de procesamiento y la ausencia de conexiones redundantes a los efectos de prever las posibles caídas del sistema. Utilizando una analogía, imaginemos que este tipo de red funciona como un sistema de transporte que une una serie de suburbios con una metrópolis de una forma radial. Cada suburbio (*terminal*) solo tiene contacto con la metrópolis (*mainframe*) y conexión con el resto de las localidades depende del mantenimiento de la conexión con esta última: Sin conexión queda absolutamente aislada. Asimismo la caída de la metrópolis transforma en inutilizable todo el sistema de transporte.

La Internet, en cambio, constituye una red de carácter descentralizado y redundante. Descentralizado, toda vez que no existe un punto central de concentración de la información, sirviendo cada uno de los nodos de la red como un servidor.. Redundante, porque las conexiones entre los distintos elementos no son únicos sino que pueden ser suplantados por otras rutas de conexión, de forma tal que la caída de uno o varios de los servidores no impide el acceso a la información contenida en el resto de los servidores que conforman la red. Siguiendo con la comparación anterior, la estructura de la red se asemeja en este caso al trazado de las calles de una ciudad: Cada lugar (*servidor*) puede conectarse a otro mediante diferentes rutas, de forma tal que el cierre de una calle

¹ Bibliografía General del Capítulo

Federico Pablo Vives, “El nombre de dominio en Internet”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003.

Fernandez Delpech, Horacio, “Internet: Su problemática Jurídica”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001

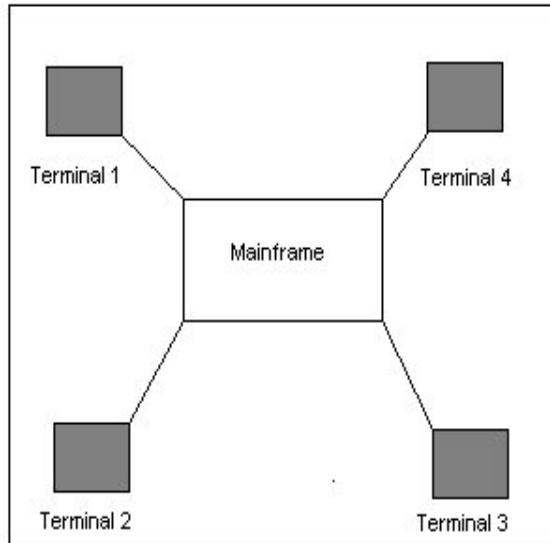
Anibal Pardini, “*Derecho de Internet*”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2002

Daniel Allmark (Director), Rafael Bielsa (Dirección Académica), “*Informática y Derecho: Aportes de la Doctrina Internacional, Tomo 8: Internet*”, LexisNexis, Buenos Aires, 2002.

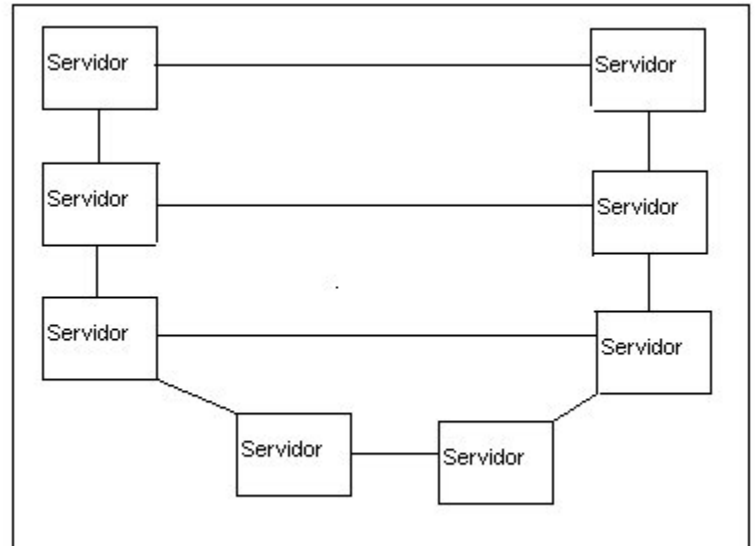
no implica un problema para los usuarios situados en el otro extremo: Simplemente deberán utilizar un camino distinto a los efectos de llegar a destino.

En un gráfico

Mainframe



Internet



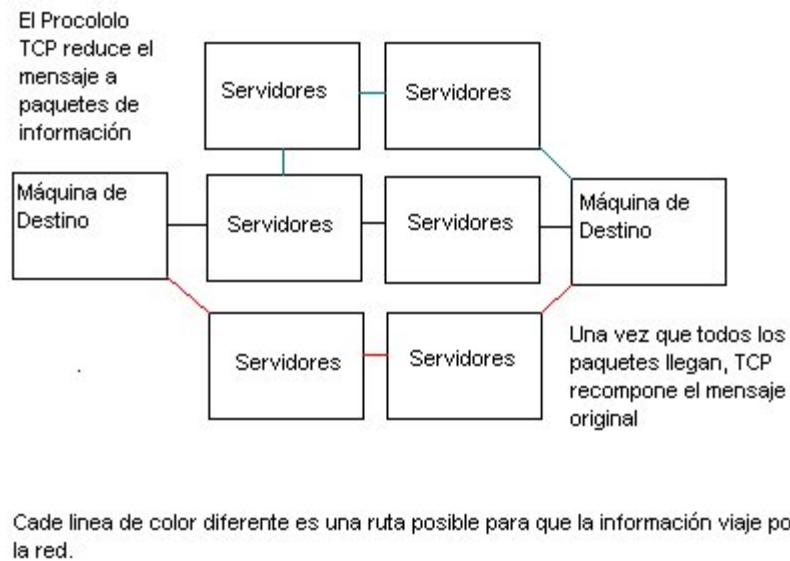
Nota A los efectos de claridad se han eliminado algunas conexiones

Fundamento técnico de la forma de conexión utilizada por Internet, lo constituye el protocolo conocido como TCP/IP. Un protocolo de comunicación es una forma standard de transmisión de datos entre dos máquinas de forma tal que tanto la receptora como la emisora puedan entender y decodificar el mensaje.

En el caso de la Internet, en realidad nos encontramos ante dos protocolos: El TCP o protocolo de control de transmisión y el IP o protocolo de Internet. El primero de ellos deconstruye el archivo a enviar en una serie de elementos menores o paquetes de información los cuales viajan por la red hasta la computadora de destino donde el TCP de esta última vuelve a ordenar los paquetes a los efectos de obtener el archivo original.

La forma en la que estos paquetes de información viajan es mediante el IP o protocolo de Internet. El mismo envía paquetes de información a través de la red mediante la elaboración de guías donde se establece una ruta a través de los distintos servidores. En caso de que alguno de los servidores no estuviera disponible, el IP del último servidor elaborará una nueva guía, conteniendo un nuevo derrotero para el paquete a enviar.

En un gráfico:



Internet y World Wide Web:

En un error común entre los usuarios de la Internet la confusión entre esta y la denominada World Wide Web o simplemente Web. Si bien muchas veces ambos términos son utilizados como sinónimos, en realidad ambos términos denotan cosas diferentes.

Tal como vimos anteriormente, la Internet constituye una red global de computadoras de carácter descentralizado. La Web, en cambio, es un subconjunto de la misma, un grupo de documentos que trabajan utilizando un standard específico: el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP.

La Web trabaja sobre una serie de documentos que se relacionan entre si, formando lo que comúnmente se conoce como "*paginas*" las cuales no son otra cosa que un conjunto de ordenado de archivos (sonido, gráficos, texto o vídeo, por ejemplo) los cuales son accedidos a través de los llamados "*hipervinculos*" o "*hipertextos*".

Hipertexto es un texto que contiene una conexión o "*link*" a otro documento. Este permite acceder rápidamente a la información relacionada con el texto que se esta leyendo. Esta información puede esta contenida en el mismo archivo o en otro ubicado incluso en un servidor diferente.

Forma en la que se programan estos hipertextos es por medio del HTML o lenguaje de adiciones de hipertexto. El mismo consiste en un conjunto de instrucciones relativamente sencillo a los efectos de definir como se estructura la pagina. Fundamentalmente, define cuales son los bloques de texto que componen cada documento, asi como cuales son las conexiones que deben realizarse a los efectos de incorporar archivos de otros medios o remisiones a otras páginas. El browser interpreta los comandos de HTML que recibe y presenta el documento formateado, tal como lo menos en la pantalla de la PC

Evolución Histórica de la Internet:

El primer esbozo de la estructura de la Internet data del año 1962 a través de serie de trabajos elaborados por J.C.R. Licklider acerca de lo que él dio en llamar el concepto de *Galactic Network*. En ellas se expresaba la idea de una serie de computadores conectados a una red global a los efectos de compartir archivos y realizar tareas en conjunto. Ese mismo año Licklider se transformó en el jefe de investigaciones del departamento de investigaciones avanzadas del departamento de defensa de los Estados Unidos (ARPA), instituto que el año 1969 y bajo la dirección Lawrence Roberts lanzó la llamada ARPAnet, la cual en un principio solo conectaba las Universidades de Stanford y la Universidad de California (UCLA).

Durante la década del setenta se elaboraron la mayoría de las aplicaciones y protocolos utilizados en la red, entre los cuales se pueden citar: el e-mail (1972) y el TCP/IP (1974)²

En el año 1984 la Fundación de Ciencias Naturales de los Estados Unidos elabora una nueva red, paralela a la ARPAnet, a los efectos de compartir la capacidad de calculo instalada por dicha institución con las universidades, proyecto que era imposible con la ARPAnet, atento que la misma ya se encontraba saturada.

La Wold Wide Web, recién comenzó a funcionar en el año 1989, de forma marginal atento la inexistencia de una interfaz eficiente para su uso. Recién en el año 1993, se dio a conocer el primer Browser (navegador) de internet, el Mosaic.

En el año 1990, el gobierno americano retira definitivamente el ARPAnet y otorga el control de internet a la Fundación de Ciencias Naturales (NSF). A su vez, el NSF se retira de la Red en el año 1995, dejando la regulación técnica de la red a un grupo de operadores privados.

De este modo, podemos ver una evolución en la concepción misma de la Internet, desde un proyecto militar hasta un emprendimiento privado, pasando por una herramienta de investigación. Es llamativo como el retiro de la gestión académica de la red condice con la adopción por parte del público masivo de los primeros browser exitosos, el Netscape Navigator y el Microsoft Explorer.

Efectos Jurídicos de la Internet:

Muchos autores han calificado a la Internet como un espacio virtud ausente de derecho. Esta concepción, que tiene su origen en los albores de la Internet, se basa en un modelo de cooperación e intercambio de información entre los distintos participantes de la red. Sin embargo, hoy es imposible sostener dicha postura: La irrupción de la economía de masas a un ámbito anteriormente exclusivamente académico, ha traído consigo la creación de nuevas relaciones jurídicas entre los contratantes e incluso entre los meros usuarios de la red. Asimismo, el explosivo crecimiento de la estructura de la Internet hace necesaria el control, por lo menos en sus aspectos técnicos.

² En realidad la primera versión del protocolo es del año 1961, sin embargo recién logra estabilizarse tal como lo conocemos hoy en el año 1974.

El control sobre la red: La sociedad de Internet:

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en ocasión de fallar respecto a la constitucionalidad de la llamada “*Acta de Decencia*”, la cual implicaba una restricción a los contenidos que podían publicarse en la red sostuvo que “Ninguna persona, compañía, institución u organización gubernamental es dueña de Internet, ni tampoco lo gobierna, o incluso tiene un interés controlante...”³

En realidad, si bien la aseveración del máximo tribunal estadounidense no es del todo errada, ello no implica que la red carezca de control, sino que simplemente no existe una persona física o jurídica que pueda de por sí atribuirse poder de disposición sobre la misma.

Sin embargo, ello no impide la existencia de un organismo de control de la internet, el cual, por lo menos en sus aspectos técnicos ejerce un control sobre ella.

La Sociedad de Internet es una organización no gubernamental, sin nacionalidad definida ni fines de lucro. Esta formada por organizaciones de ciento sesenta y cinco países, cuenta con más de ocho mil miembros, los cuales trabajan elaborando políticas y prácticas para ser adoptadas por la red, como asimismo supervisan el trabajo de las organizaciones, grupos de tareas, que trabajan en las decisiones políticas de la red.

Entre las organizaciones que se encuentran bajo la supervisión de la Sociedad de Internet se encuentran:

1- IAB: Junta de Arquitectura de Internet: Es el grupo de consultores técnicos de la Sociedad de Internet. Son sus responsabilidades:

A- Nombra a las autoridades del IETF y a los miembros del IESG

B.- Vigilancia de los standard de proceso y apelación. Supervisa los procesos a los efectos de crearlos standards de Internet. Además, actúa como un consejero de apelación respecto a las divergencias respecto a la ejecución de dichos standards.

C.- Nombres de Dominio. Asigna y controla los nombres de dominio de primer orden. No los territoriales, los cuales quedan a cargo de las autoridades locales.

D.- Representación: Representa a la Sociedad de Internet en las cuestiones atinentes a standards y cuestiones técnicas en los casos que estas repercutan en la red.

Asimismo la IAB tiene bajo su supervisión una serie de organizaciones en las que podemos mencionar:

IANA: Autoridad de Asignación de Números: Es el organismo encargado de otorgar los nombres de dominio en Internet.

IETF: Grupo de trabajo de Ingeniería de Internet: Es la encargada del desarrollo de los protocolos de Internet.

IESG: Grupo de dirección de Ingeniería de Internet: Es el responsable de la del manejo técnico de las actividades de Internet. Como parte de la Sociedad de Internet administra el proceso de acuerdo sobre las especificaciones técnicas y estándares de la red.

³ SC de los Estados Unidos de Norteamérica, 26/6/97, “Janet Reno c/American Civil Liberties Union”

- 2- IRFT: *Grupo de Trabajo de Investigación de Internet*: Es el organismo encargado de la investigación respecto a los aspectos técnicos de la Internet, para lo cual cuenta con grupos de estudio a corto y largo plazo, trabajando en el estudio de los protocolos y arquitectura de la red.
- 3- ISTE: *Grupo de Trabajo Social de Internet*: Es el organismo encargado de la elaboración de las políticas tendientes al máximo aprovechamiento social de la red, entendiendo al mismo como posibilidad de todos los habitantes de acceder a la red.

A dichos efectos es la encargada de analizar las características económicas, sociales y educacionales de las distintas zonas del planeta a los efectos de identificar cuales son los principales obstáculos para el acceso universal de la red.

El problema de la jurisdicción en Internet:

Una de las características fundamentales de Internet es su tendencia globalizadora, entendiendo por tal, la intención de la misma de un libre intercambio de la información contenida en la misma. La irrupción de emprendimientos comerciales, así como la masificación derivada de la World Wide Web, creó una serie de inconvenientes derivados de la posibilidad de ilícitos e incumplimientos contractuales en el ambiente digital.

Debe tenerse en cuenta que cualquier acto o hecho jurídico llevado a cabo en la red, los participantes del mismo pueden estar ubicados en varios países del mundo. Del mismo modo, el servidor en el que estas personas interactúan puede estar ubicado en un tercer lugar⁴.

Frente a este problema, el problema del derecho consiste básicamente en determinar cual es la legislación aplicable, así como la jurisdicción aplicable tanto en etapa de conocimiento como de ejecución.

Sin bien es práctica común en la mayoría de los contratos celebrados por Internet la inclusión de cláusulas que definan jurisdicción y normativa aplicable, la mayoría de estos actos jurídicos constituyen convenios de adhesión, lo que implica el riesgo jurídico que dichos acuerdos carezcan de validez por ser considerados nulos⁵ en los casos que impliquen un injustificado beneficio. Esta solución asimismo deja de lado los casos en que la instancia se habilita por actos ilícitos.

La solución de considerar el domicilio del servidor a los efectos de la jurisdicción, presenta numerosos inconvenientes, siendo quizás el más importante la posibilidad de creación de “*servidores de conveniencia*”, es decir el desplazamiento de la jurisdicción y legislación aplicable a una más conveniente mediante el mero traslado del computador a un territorio ajeno por completo a la explotación o intereses de la empresa prestataria del servicio⁶.

⁴ Imaginemos, por ejemplo, el caso de un remate en línea utilizando un servicio como E-bay entre un sujeto ubicado en España y otro argentino. En este caso, el servidor sería americano, un contratante se regiría por la legislación española y el otro por la argentina.

⁵ En este caso se estaría frente a una cláusula abusiva, cuestión cuyo estudio corresponde al derecho del consumidor.

⁶ Este fenómeno se ha producido particularmente en el campo del derecho de la navegación con las llamadas banderas de conveniencia.

La solución contraria, otorgar la jurisdicción en el territorio del reclamante, no esta tampoco exenta de problemas, toda vez que somete a la empresas y particulares que utilizan la red al riesgo de verse sometidos a cualquier régimen jurídico o jurisdiccional sin posibilidad de control alguno.

En la República Argentina los casos relacionados con Internet se han dado con relación a las disputas derivadas de la titularidad de los nombres de dominio, los cuales no llegaron a tener sentencia definitiva. En dichos casos las acciones se basaron en la violación de la ley de marcas, por lo que el análisis debería darse en dicho ámbito y no en el presente trabajo.

En los Estados Unidos, los tribunales se han elaborado diversas doctrinas a los efectos de definir la legislación y jurisdicción aplicable al misma. Si bien el problema no ha obtenido una respuesta definitiva, una de las soluciones mas aceptadas es la aplicación de la doctrina del *Long Arm*, la cual se basa en el otorgamiento de la jurisdicción personal según los beneficios que el demandado pudo haber obtenido mediante la realización de transacciones o mediante la posibilidad de las mismas.

A los efectos de entender dicho enunciado, analizaremos la sentencia judicial recaída en autos “*American Network Inc. C/Access America*”. En dicho caso, un proveedor de Internet de Nueva York demando por violación de marca a un segundo proveedor, el cual si bien tenía su domicilio en Georgia, ofrecía sus servicios mediante su página web a personas indeterminadas, incluidas los habitantes del estado de Nueva York . El demandante sostenía la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, pretensión que fue admitida merced a los siguientes argumentos:

1.- Si bien el demandado cometió el hecho en otro estado, el demandado sufrió un daño en el de Nueva York, al ser confundida su marca con la perteneciente a la pasiva.

2.- Era previsible para el demandado que su actividad tuviera repercusiones en Nueva York, toda vez que ofreció su servicio a clientes de todo Estados Unidos y había aceptado suscriptores en dicho estado.

3.- Merced a dicha actividad el demandado recibió un rédito mensurable, circunstancia que no fue rebatida por el mismo.

En virtud de ello, la corte entendió que la jurisdicción se encontraba habilitada. Por tanto y a los efectos de cerrar el tema enunciaremos la regla del Long Arm⁷:

La Corte puede ejercer la jurisdicción personal sobre cualquier no residente que cometa un acto delictivo fuera del Estado causando daño a personas o propiedades dentro del estado, si el pudo esperar o razonablemente debió prever que el acto tenga consecuencias en el Estado y obtuvo un beneficio sustancial del comercio interestatal o internacional

Parte 2 Régimen Legal del Nombre de Dominio:

Definición:

⁷ La siguiente enunciación se basa en el art. 302 del código de procedimientos del estado de Nueva York

Cualquier designación alfanumérica que se registra o asigna y forma parte de una dirección electrónica⁸

En realidad, las direcciones en Internet se expresan mediante una secuencia indentificatoria de números separados por períodos o campos siguiendo un criterio de menor a mayor especificidad, de forma tal que el primer número corresponde a la red, el segundo a una subred dentro de la principal, así hasta llegar a la última cifra que corresponde a la computadora que se intenta acceder.

Sin embargo, este sistema es altamente engorroso para el usuario medio de la red, por lo que esta secuencia puede ser traducida o asociada a una expresión alfanúmerica de forma tal que sea más sencillo de recordar. Verbigracia:

<http://204.162.80.183>
es exactamente lo mismo que
<http://www.cnet.com/>

Por tanto las direcciones numéricas son traducidas mediante un sistema de nombres de dominio conocido como DNS en una expresión alfanúmerica. Esta solución técnica, que permite un mejor acceso a la red, implica una serie de problemas jurídicos, toda vez que los distintos emprendimientos han intentado vincular sus nombres de dominio a la sus marcas comerciales, a los efectos de beneficiarse con las campañas de Marketing elaboradas en el mundo real.

2 El DNS. Funcionamiento. Principios:

El DNS es un protocolo de traducción de identificaciones numéricas en una cadena alfanumérica que pueda ser fácilmente recordada por el usuario. Sin embargo, dicha cadena alfanumérica no es uniforme y presenta distintos elementos cuya protección jurídica es disímil. Tomemos nuevamente el ejemplo:

<http://www.cnet.com>

En la dirección podemos ver dos elementos diferenciados: Una parte exclusiva (CNET) y otra genérica como es la expresión “.com”. Este último elemento, conocido como dominio genérico, carece de la protección otorgada al elemento específico, toda vez que constituye una convención aceptada por todos los usuarios de la red que en el caso particular denota que se trata de un sitio comercial.

Con respecto a dichas convenciones, las mismas se pueden dividir en dos grandes grupos según que su registración se encuentre limitada o no. Entre aquellos dominios genéricos reservados podemos nombrar a “.gov” para organismos de gobierno, “.int”, para organismos supranacionales y “.mil” para entidades militares. En los dominios libres se encuentran “.com” (empresas comerciales), “.net” (redes informáticas) y “.org” para entidades sin fines de lucro y asociaciones en general. En el año 2000 se aprobó la creación de nuevos dominios, los cuales todavía se encuentran sujetos a implementación: “.info” y “.biz” para información general, “.pro” para profesionales “.name” para sitios

⁸ Esta es la definición que a los efectos legales, ha elaborado la legislación de los Estados Unidos de América en la “*anticybersquatting consumer protection Act*”

personales, “.museum” para museos “.aero” para aerolíneas comerciales y “coop” para cooperativas.

Tradicionalmente las DNS solo contaban con genéricos que no denotaban origen geográfico, por lo que el registro de un nombre de dominio impedía el registro de otro similar en todo el mundo. Hoy en día, a los efectos de la diferenciación de las distintas páginas se han agregado los genéricos geográficos, los cuales son normalmente administrados por una entidad local⁹.

Por ejemplo, supongamos que el sitio anterior abriera una filial para la argentina y otra en brasil, lo que haría que hubiera dos nuevos nombre de dominio:

<http://www.cnet.com.ar>

<http://www.cnet.com.br>

Como podemos ver en los ejemplos, se ha agregado con posterioridad al genérico “com” dos nuevas siglas, que denotan la nacionalidad del sitio, ya sea argentina (.ar) o brasil (.br).

Administración de los nombres de dominio. Su registración:

Atento a la existencia del desdoblamiento anteriormente mencionado el Régimen Argentino de nombres de dominio se encuentra regulado por un organismo internacional y otro nacional con competencia exclusiva en lo que respecta a los dominios .ar.

En la República Argentina la regulación de los nombres de domino se rige por la resolución 2226/00 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el cual plantea un sistema particularmente laxo en lo referente a los requisitos y formalidades necesarias para la inscripción del nombre de dominio.

El registro del nombre de domino se realiza mediante un formulario electrónico disponible en el sitio Web de Nic-Argentina, el cual cumple la doble función de declaración jurada respecto de los datos a ingresar y aceptación de los términos y condiciones que, respecto al servicio, impone la reglamentación.

El sistema utilizado para la registración en estos casos sigue el principio de *“primero en el tiempo, primero en el derecho”*, sin que la autoridad de aplicación realice un examen exhaustivo de la legalidad del uso del nombre. De esta forma, Nic-Argentina elude toda responsabilidad derivada de daños por violación a la ley de marcas o cualquier otro perjuicio a terceros, quedando en cabeza del registrante dichos riesgos. Sin embargo, y excepcionalmente, es facultad de Nic-Argentina la posibilidad de rechazar una petición por considerar que la misma implica la violación flagrante de una marca conocida o una invasión a la privacidad de una persona física.

En realidad, los únicos límites impuesto por la reglamentación son los derivados de la moral y las buenas costumbres y la imposibilidad de registrar nombres de dominio ya existentes. Como excepción, se impide el registro de

⁹ En el caso del genérico “.ar” el mismo se encuentra a cargo del servicio Nic-Argentina, el cual depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

nombres de dominio que se correspondan con organismos estatales o aquellos que lleven el genérico .GOV los cuales corresponden a reparticiones estatales y conllevan un sistema de registro un poco más complejo.

Con respecto al plazo, el registro del nombre de dominio es válido por un año renovable, sin que exista límite a la cantidad de veces que esta facultad se utiliza. Igualmente la autoridad de aplicación se reserva el derecho a rescindir el registro en los casos en que la información entregada sea falsa, exista orden judicial a dichos efectos o cuando razones de fuerza mayor o conveniencia técnica así lo impongan.

La relación entre el nombre de dominio y las marcas comerciales : El cybersquatting

Si bien en numerosas ocasiones se han equiparado el nombre de dominio a una marca comercial, los primeros presentan características distintivas que impiden su asimilación.

En primer lugar, la protección otorgada a las marcas comerciales mantiene una doble limitación: en un aspecto material, imposibilita solamente la utilización de homónimos respecto a productos similares o que de alguna manera puedan ser relacionados con la marca protegida¹⁰; y en el ámbito territorial la prohibición se circunscribe solamente al territorio del país donde de la marca sea a registrado. Los nombres de dominio, en particular los de primer orden, carecen de esta diferenciación: Mientras puede haber varios negocios llamados Gomez dentro de un mismo territorio, siendo uno dedicado a la cría de ganado y el otro a la venta de artefactos de baño, el nombre de dominio www.gomez.com es único para todo el orbe e impide diferenciar cuales son las actividades realizadas por el titular.

En segundo lugar, las marcas mantienen una identidad iconográfica de la que carecen los nombres de dominio: Mientras, verbigracia, la marca Coca Cola mantiene un logotipo y tipografía identificable, propia y susceptible de defensa jurídica, el nombre de dominio <http://www.cocacola.com> no resulta modificado por la tipografía o características gráficas utilizadas para su inclusión en el browser.

Por último, mientras que las marcas denotan la existencia de productos en el mercado, los nombres de dominio no necesariamente implican una actividad comercial, pudiendo ser simplemente paginas personales o sin ningún tipo de interés comercial.

Por lo tanto, no es posible asimilar los nombres de dominio a las marcas comerciales, lo cual, sin embargo, no impide que entre ambas figuras se produzcan relaciones. Tal como ya adelantamos, es innegable el beneficio que para las empresas significa el aprovechamiento del prestigio de sus marcas comerciales en sus estrategias en la Web, interés que puede verse frustrado por el mero registro del nombre de dominio por parte de un tercero con la única intención

¹⁰ Estos fenómenos son conocidos como *dilución de la marca comercial* en los cuales sin bien no se usurpa el nombre se lo daña conectándolo con productos de menos calidad o que no tiene directamente que ver con el mismo, haciendo de esta forma que la marca pierda identidad.

de lucrar con su venta. Esta práctica, lamentablemente, se ha vuelto tan común que ha recibido un nombre para identificarla: *Cybersquatting*¹¹.

Frente a este fenómeno el ordenamiento jurídico se encuentra frente a dos problemas: El primero de fondo, consistente en entender cuándo nos encontramos frente a una apropiación ilegal de un nombre de dominio; el segundo es encontrar la vía procesal idónea para entender en el conflicto.

En la república argentina, si bien no existe todavía una legislación que reglamente este fenómeno, las vías procesales utilizadas a los efectos de la solución de los conflictos que se han suscitado han sido tanto la judicial como los procesos arbitrales ofrecidos por el NIC-Argentina.

Los medios judiciales empleados tienen su fundamento en acciones basadas en el derecho de marcas, las cuales son presentadas ante los tribunales federales del domicilio del demandado o capital federal, atento que el lugar de registro es el Ministerio de Relaciones Exteriores con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Las experiencias jurisprudenciales argentinas presentan la particularidad de carecer de sentencia firme, al ser la mayoría de las medidas cautelares obtenidas de carácter autosatisfactivo. Así por ejemplo en los autos caratulados *Heladería Freddo S.A. c/Spot Network*¹², el juez de la causa otorgó el uso del dominio a la actora, por entender la coincidencia en una partícula del nombre de dominio y una marca registrada constituía un uso indebido de esta última.

Esta tendencia, que se repitió en otros casos como *“Pugliese, Francisco c/Perez, Carlos”*¹³, plantea un problema de base que es la asimilación de los nombres de dominio a las marcas comerciales, de forma tal que la mera inclusión de una marca comercial implica necesariamente una infracción sancionable. La cuestión, que aparece como una solución positiva desde el punto de vista axiológico en el caso “Freddo”, no parece tan claro en la segunda hipótesis analizada, toda vez que los elementos de hecho varían en forma sustancial: En primer lugar, no existe una marca claramente reconocida en el mercado que necesariamente implique una privación de ganancias por la imposibilidad de explotación. En segundo lugar, en este caso el titular del dominio se encontraba utilizando el mismo a los efectos del mantenimiento de una página personal, la que coincidía con las siglas de su nombre. La resolución de la Cámara en lo Civil y Comercial, entonces, al asimilar de manera automática el nombre de dominio con la marca comercial, no solo se aparta del régimen del nombre de dominio sino que incluso viola el principio de especialidad contenido en el régimen de marca comercial al extender de manera universal la protección dada al titular de una categoría, en detrimento del resto de los posibles titulares marcarios.

En lo que respecta a las soluciones arbitrales, las mismas encuentran su fundamento en una cláusula compromisoria elaborada por la IANA a los efectos de saldar las controversias que pudieran suscitarse respecto a la asignación de los

¹¹ *Squatting* es la práctica, bastante extendida en ciertos países de Europa, consistente en la ocupación de inmuebles abandonados por parte de comunidades de jóvenes.

¹² Juzg. Nac. Civ y Com N° 7 sec. 13 c.5354

¹³ Juzg. Nac. Civ. y Com. Fed. Sala 2° c5050/1999

nombres de dominio, la cual es aceptada al momento de registrar el nombre de dominio en la autoridad de aplicación ya sea la IANA o la autoridad local, en nuestro caso Nic-Argentina.

El régimen de fondo respecto al tema esta dado por un documento denominado *Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio* y su respectiva reglamentación.

Respecto al procedimiento, debe destacarse que la IANA no realiza directamente el arbitraje sino que autoriza a un número limitado de empresas arbitrales, las cuales deben elaborar un reglamento de aspectos de trámite a los efectos de ser reconocidas como tales y obtener de esa manera el carácter de obligatorio para sus resoluciones.

Sin intentar ahondar en los pormenores del procedimiento, debemos sin embargo enumerar sus principales características:

- 1- Es un proceso voluntario: Tanto para el demandado que acepta el mismo en momento del registro como para el demandante, quien lo hace al momento de iniciar el procedimiento.
- 2- Permite un conocimiento pleno: Más allá de las características que cada proveedor le otorgue a través de su reglamentación, ambas partes deben ser oídas mediante una demanda y su constestación.
- 3- Es arbitral: La cuestión es resuelta mediante laudo fundado emitido por un tribunal unipersonal o colegiado de expertos en la materia.
- 4- Es obligatorio: La resolución arribada tiene carácter obligatorio para las partes y abre una instancia de ejecución en el caso de desconocimiento o reticencia por alguna de las partes.

Es asimismo de notar que el art. 4 inc a de la *Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio* define claramente cuales son los extremos a acreditar al momento de acreditación de la demanda, enunciación que resulta útil a los efectos de entender cuándo se esta frente un caso de Cybersquatting. Los supuesto a acreditar son:

- 1- El nombre de dominio registrado debe ser idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas de productos o servicios sobre los que el demandante tiene derechos: A respecto debe tenerse en cuenta que los nombres personales cuando los mismos son lo suficientemente conocidos pueden asimilarse a una marca comercial¹⁴
- 2- El titular del nombre de dominio carece de título o interés legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.
- 3- El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe: A este respecto se han entendido que constituyen indicios de mala fe:
 - a. El registro con propósito de venta del nombre de dominio.
 - b. El registro a los efectos de impedir el uso normal de la marca, cuando esto constituya un patrón de conducta.
 - c. El registro de marcas de la competencia al solo efecto de entorpecer su giro normal
 - d. El intento de atraer visitantes con fines comerciales, sacando provecho de la confusión con la marca comercial.

¹⁴ Al respecto ver “Julia Fiona Roberts c/Russel Boyd”

Parte 3: Responsabilidad Civil en Internet

Introducción

Tal como vimos al tratar la estructura de Internet, entre el emisor de un mensaje y su receptor podemos encontrar una serie de sujetos jurídicos prestando diferentes servicios, incluso en forma involuntaria.

Atento ello, la hipótesis de la existencia de contenidos contrarios a derecho o dañosos presenta el problema de determinar el grado y la naturaleza de la responsabilidad de los intervinientes en el hecho.

Esta cuestión dista de ser meramente teórica por dos motivos básicos: el primero la dificultad de establecer el verdadero autor del mensaje, la segunda la posibilidad que, una vez hallado, carezca de bienes suficientes para afrontar los daños producidos.

A continuación analizaremos cada uno de los intervinientes en el proceso e intentaremos determinar su responsabilidad.

Proveedores de Acceso a Internet:

Los proveedores de acceso son los sujetos jurídicos que prestan la infraestructura técnica para que los proveedores del servicio de Internet ofrezcan su servicio.

En razón de su función, los proveedores carecen de control y acceso a los contenidos que circulan por la web, por lo que no podría reputárselos responsables civiles de los mismos. En este sentido, Pablo Bolotnikoff¹⁵ los asimila a las empresas prestatarias del servicio telefónico, en tanto su falta de responsabilidad por los contenidos que por el medio se transmita.

Servicios de Caching

El servicio de caching almacena en forma automática, provisional y temporaria cierta información con el único fin de que sea más eficaz la transmisión la misma.

En principio carecen de control sobre el contenido de almacenado, por lo que se les debe eximir de responsabilidad. Este es el principio establecido por artículo 13 de la Directiva Europea de Comercio Electrónico 200/31¹⁶ en tanto establece que *Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio*

¹⁵ Bolotnikoff, *Informática y Responsabilidad Civil*, La Ley, Bs As, 2004.

¹⁶ Publicada el 17-07-2000 disponible en su versión en español en <http://consumo-inc.es/guiacons/interior/otrosdocumentos/comelectronico/documentos/Directiva%202000-31.htm>

Sin embargo, es posible que el proveedor de caching tenga acceso al contenido o capacidad para controlarlo o modificarlo. En tales casos la eximente de responsabilidad desaparece, criterio sustentado por las excepciones contenidas en la segunda parte del art. 13 de la directiva 2000/31.

Proveedor de Contenido

Entendemos por proveedor de contenido todo aquel que coloca archivos informáticos en la web con el fin de que terceros accedan a ellos. La Communications Decency Act los denomina *Information Content Providers* y los define como *“cualquier persona o entidad que es responsable, en todo o en parte, por la creación o el desarrollo de información provista a través de Internet o cualquier otro servicio interactivo de computadoras”*

Sobрино¹⁷ diferencia entre los productores de contenido según que los mismos creen contenidos propios o refieran a contenidos ubicados en paginas realizadas por terceros. En el primero de los casos la responsabilidad del proveedor de contenido es clara atento el carácter de autor del contenido. La cuestión es más compleja en los casos de referencia a material de tercero.

Técnicamente, la forma de referir a material de terceros es la generación de hipervínculos a la dirección de Internet donde se encuentra disponible el mismo. A su vez, esta página puede contener nuevos links a otros sitios de Internet y así sucesivamente. Por tanto podemos diferenciar entre contenidos indirectos de primer nivel y de segundo, sea que el acceso se produjo desde la página original o desde la referida.

Desde el punto de vista de la responsabilidad parece clara la obligación de responder del proveedor de contenido por los contenidos de primer orden. Si bien no es el autor, el proveedor de contenido realiza una acción voluntaria al vincularse al contenido objetable, permitiendo el acceso desde su sitio a los terceros.

Con respecto al contenido de segundo orden, extender la responsabilidad respecto de los mismos aparece como excesivo atento la inexistencia de un control o conocimiento directo del proveedor de contenido

Proveedores de servicio de Internet

Se entiende por proveedor de servicio de Internet a los sujetos jurídicos que permite a los usuarios particulares acceder a la Internet. Asimismo y en forma habitual, el proveedor de Internet (ISP en inglés) ofrece servicios de Hosting, permitiendo a los usuarios colocar contenido en Internet a disposición de terceros.

¹⁷ Sobrino, Walter *“Responsabilidad de la empresas proveedoras de servicio de Internet”*, Alfa Redi, No. 025 - Agosto del 2000 Disponible en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=538>

Es necesario determinar la naturaleza jurídica de la actividad, ya que se han elaborado diversas posturas sobre la atribución de responsabilidad por los contenidos ilícitos se propaguen a través de sus servicios.

Una corriente propugna una analogía entre quienes alojan las páginas web y los editores de una obra cualquiera, en el sentido de que ambos proporcionan el soporte material que permite a los autores la divulgación de los contenidos generados, y tienen injerencia en su redacción y/o producción final. De ésta forma los ISP tendrían una responsabilidad directa sobre los contenidos que publican, al igual que los editores lo hacen con sus obras.

Otra postura asimila los ISP a los propietarios de librerías, de manera que se reconoce la imposibilidad de controlar el volumen de información que los usuarios introducen en el servidor.

Esta última es la postura que aparece adoptarse en el derecho comparado. Así la Directiva Europea 2000/31 establece por principio en su art. 14 la ausencia de responsabilidad de los proveedores de hosting mientras el mismo no tenga conocimiento efectivo de la actividad ilegal. En el mismo sentido, la *Communications Decency Act* de Estados Unidos consagra la inmunidad de los proveedores de hosting en la sección 230, negando incluso el carácter de editor.

Jurisprudencialmente, los tribunales han consagrado la responsabilidad de los ISP en la hipótesis que estos, teniendo conocimiento de la actividad ilícita omitan tomar las medidas necesarias para poner fin la misma. En un caso sentenciado por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, BUFFNET, un ISP ubicado en la ciudad Búfalo, fue encontrado culpable de proveer acceso a contenidos de pornografía infantil. De las constancias judiciales surge que Buffnet no había tomado ninguna acción después de ser notificado de que uno de los newsgroups que albergaba estaba distribuyendo pornografía infantil. En un reciente fallo, *Fair Housing Council Of San Fernando Valley v Roommates.com*¹⁸ la corte federal de apelaciones declaró responsable a un sitio de Internet por los contenidos subidos por los usuarios, por entender que por la forma de tratamiento de los mensajes el sitio asumía el carácter de editor, debiendo hacerselo responsable de los daños y perjuicios derivados de la actividad ilícita de sus usuarios.

La cuestión en la argentina: El caso Jujuy.com

El primer antecedente de responsabilidad de un ISP fue dictado por Camara en lo Civil y Comercial de la provincia de Jujuy in re “*SM y LEM c/Jujuy Digital Y7O Jujuy.com y Omar Lozano*” en el año 2004¹⁹.

La empresa Jujuy digital operaba el dominio Jujuy.com, en cuyo foro se publicó en forma anónima un mensaje respecto de la supuesta infidelidad de los actores. Este mensaje fue retirado luego de que el sitio recibiera intimación por

¹⁸ Disponible en <http://www.pablopalazzi.net/wp-content/uploads/2007/10/cda-caso-fair-housing-v-roomatescom.pdf>

¹⁹ CCivCom Jujuy, Sala I, 30/6/04 disponible en <http://www.habeasdata.org/Caso-Jujuy>

carta documento, circunstancia que fue considerada un conducta omisiva por el tribunal y un reconocimiento de la actividad ilícita.

En sus considerandos el tribunal entendió que una vez demostrada la existencia del daño, la responsabilidad surgía en forma clara de la aplicación del art. 1113 del código civil. En esta inteligencia sostiene la analogía con la energía en cuanto la material riesgoso, considerando procedente la responsabilidad objetivo de los codemandados por los daños producidos.

El fallo merece una serie de críticas. En primer lugar, la aplicación de los criterios de responsabilidad objetiva aparecen apartados de la legislación y jurisprudencia comparada, creando un posible riesgo jurídico para las empresas que prestan servicios de hosting o simplemente permiten a los usuarios expresar una opinión. En segundo lugar, la analogía utilizada no aparece como la más feliz. El análisis realizado establece un doble estándar de responsabilidad según si el mensaje fue realizado mediante un medio tradicional o vía web, ignorando el hecho que el daño se produce por la existencia del mensaje y no por la utilización de la herramienta informática.